

1500618-35.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500618-35.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117017/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24646078 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2117017 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

01) JORGE LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO;

02) WILIAN DO NASCIMENTO FARIAS.

Artigo da Denúncia:

Art. 35 "caput" e Art. 33 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

14/07/2022

Em 14 de julho de 2022, às 13h30, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. Drª MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MMª Juíza de Direito Titular, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, pela MMª Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da Drª Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, DD. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus WILIAN DO NASCIMENTO FARIAS e JORGE LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO, bem como as suas respectivas Defensoras, Drª Elisabete Moreira Branco OAB 75278/SP e Drª Elaine Cristina dos Santos Pontes OAB 160283/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual, as testemunhas arroladas pela Acusação, Sandro de Oliveira e Márcio José Coelho. INICIADOS OS TRABALHOS, possibilitou-se que as Defensoras se entrevistassem reservadamente com os acusados. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiências foi realizada por meio de videoconferência,

através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo, com a posterior importação dos arquivos no sistema informatizado SAJPG5. Na sequência, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: Vistos. Os réus JORGE LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO e WILIAN DO NASCIMENTO FARIAS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no mês de abril de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; e 2) em 29 de abril de 2022, por volta das 14h30, na rua Alceu Vieira, nº 132, bairro Tanquinho, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 02 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 67,46 gramas; 07 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 6,11 gramas; e 01 porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 11,04 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados praticavam o tráfico de drogas, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Procediam à pesagem e ao preparo dos invólucros, no interior do imóvel, e, posteriormente, faziam as entregas aos adquirentes. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram os acusados saindo da casa. JORGE e WILIAN, ao notarem aproximação da viatura, tentaram retornar à residência, oportunidade em que WILIAN arremessou algo para a casa vizinha. Houve a abordagem e o objeto lançado foi localizado, tratando-se de sacola contendo 01 porção de "maconha", 02 porções a granel de cocaína e 07 invólucros de cocaína, além de balança de precisão, embalagens vazias (58 microtudos do tipo "eppendorf" e 39 pequenos sacos plásticos tipo "ziploc") e folhas como anotações contábeis acerca do comércio ilegal. Em revista pessoal, com WILIAN foram encontrados R\$130,00. Os réus foram notificados (fls. 82) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 91/96 e 99/105). Assim, por decisão proferida no dia 12 de julho de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 109/111). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com os interrogatórios dos réus, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição dos réus, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 31/32 e 34/35, bem como Certidões a fls. 33 e 36. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Preliminarmente, faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Ainda sobre a desnecessidade de mandado de busca domiciliar decorrente do estado de flagrância pela natureza do delito em espécie, segue a jurisprudência - EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do

objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 213852 AgR, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 30/05/2022, Publicação: 01/06/2022) Os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de “qualquer pessoa do povo” seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, “qualquer do povo” poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de “garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas”, consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. Superada portanto a preliminar arguida, passo ao exame do mérito. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:” (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o

seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e a ré exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e a acusada, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 75/77) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu WILLIAN, em solo policial (fls. 04), manteve-se silente. Em juízo, o réu disse que no dia dos fatos escutou um barulho no portão, o cachorro começou a latir, Jorge saiu para atender e os policiais disseram que estavam ali por causa da moto. Quando Jorge foi atender, eles ingressaram na casa e ele jogou a sacola no vizinho. Não sabe que tinha dentro da sacola. Estava devendo, estava sendo ameaçado e o rapaz pediu para ele guardar a droga. Não sabe o que tinha na sacola, se tinha a balança de precisão ou outras coisas. Jorge não tem nenhuma participação. Jorge morou um tempo em sua casa pois havia brigado com o pai dele. Essa casa é de sua mãe. O dinheiro que estava na sua carteira, R\$130,00 era para pagar uma conta. Esse dinheiro era de sua irmã. Não conhecia os guardas municipais. Os policiais falaram que eles tinham que dizer que estavam fora e correram para dentro, mas não foi isso, estava dentro da casa. Hoje está registrado na Provasi, ganhava cerca de R\$1500,00, mas quando dos fatos estava desempregado. E solteiro. Nunca foi processado. Não é traficante, é usuário. Cheira e fuma. Cuida da casa, pois sua irmã quer cursar direito. Não pode falar de quem é a sacola, pois pode morrer. Ganhava dinheiro e droga para guardar a sacola. Jorge é seu primo. Verifica-se que o réu Willian admitiu a prática do tráfico na medida em que armazenava entorpecentes para terceiro e mediante contraprestação, quer seja o pagamento de dívida, quer seja a obtenção de droga para o próprio uso. Entretanto o réu negou a participação do corréu Jorge com evidente intenção de eximir de responsabilidade o comparsa do crime, versão que não se mostra consistente e não se ampara em qualquer elemento probatório. Por sua vez, o acusado JORGE, em solo policial (fls. 05), também se manteve silente. Em

juízo, disse que no dia dos fatos bateram palma na casa e o cachorro começou a latir. Perguntaram se o cachorro era manso e entraram com tudo. Não correu, apenas foi atender o portão. Não conhecia esse guardas. Eles não teriam motivo para prejudica-lo, mas nega que tenha confessado o trafico. Fazia 4 meses que estava morando na casa. Não sabia que Willian guardava substancia entorpecente no local. Estava desempregado há 15 dias quando da abordagem. É solteiro. Nunca foi processado. Faziam uns bicos e sua prima também trabalhava na Zanqueta, mas era mais ela que mantinha a casa. Não estava traficando e faz uso de maconha e de pó. Usavam droga dentro da casa. No dia da abordagem tinham usado droga. A negativa do réu Jorge não prospera, primeiro porque ali residia com o corréu Willian, ambos desempregados e teriam confessado o trafico aos agentes públicos. Vejamos. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Sandro de Oliveira, em sede policial (fls. 02), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pela Rua Alceu Vieira, Bairro Tanquinho, quando avistaram dois indivíduos saindo de uma residência de nº 132. Ao avistarem a viatura, esses dois sujeitos tentaram retornar para dentro do imóvel. Um dos suspeitos arremessou algo para casa vizinha. Devido a atitude efetuaram, abordaram os dois indivíduos, identificados como WILLIAN DO NASCIMENTO FARIAS e JORGE LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO. Em busca pelos objetos arremessados por WILLIAN, verificaram que se tratava de uma sacola contendo porções de substâncias aparentando ser maconha (01 porção) e cocaína (duas porções maiores - sete porções menores acondicionadas em embalagens zip loc), além de uma balança de precisão e pinos plásticos vazios. Havia, também, embalagens zip loc vazias. Ato contínuo, em revista pessoal, foi localizado com WILLIAN a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais). Com JORGE LUIZ, nada foi localizado. Em juízo, disse que se encontravam em patrulhamento pelo bairro Tanquinho e viram os réus saírem da residência e eles ao avistarem a viatura mostraram-se assustados e que correram para o interior da residência. Ingressaram no local atrás dos réus e viu um deles jogar algo para casa vizinha. Constatou-se que foi arremessado substancia entorpecente. Reconheceu o réu Willian como aquele que dispensou as drogas. Foi encontrado maconha e cocaína. Não conhecia os réus dos meios policiais. Os dois confirmaram a propriedade da droga, embora um deles tenha arremessado. A mudança de comportamento dos réus e a atitude de correr que levantaram suspeitas, sendo que um deles já estava com a sacola na mão. Ambos os réus confessaram que há pouco tempo vinham traficando. Não alegaram que a droga era para uso e não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, o Guarda Civil Municipal Marcio José Coelho, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Tanquinho, conhecido pelo volume de trafico e neste dia estavam descendo pela rua da casa dos dois e um deles estava com um pacote mão e em frente a residência. Os dois ao avistarem a residência correram para o interior das casa e um deles, o mais gordinho dispensou uma sacola para a casa vizinha. Também foram encontradas anotações. O réu confessou ter arremessado a sacola com as drogas e ambos confessaram o tráfico, alegaram falta de emprego, que não estavam conseguindo se sustentar. Os dois estavam morando no local, sendo que um deles disse que estava ali porque havia brigado com o pai. Junto com a droga havia balança de precisão, folhas de caderno e outros apetrechos. Era o motorista da viatura e já tinha ouvido falar que eles faziam a distribuição de droga no bairro, mas seu parceiro não os conhecia. Não os conhecia de abordagens. Confessaram a pratica do trafico há pouco tempo. Ingressaram na residência porque já tinha denuncia acerca dos dois, viram um dos réus com um pacote na mão e ainda ao avistarem a viatura eles correram para dentro da casa. Os réus não alegaram que a droga era para uso e não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a

verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Quanto a alegação da defesa de que o depoimento dos guardas restaram lacônicos quanto as informações anteriores, ou o reconhecimento do réu que dispensou a droga, entendo que são periféricas e não afastam a validade do relato, que foi preciso em narrar a dispensa da droga por um dos réus, o comportamento suspeito e a confissão formal. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram, verossimilmente, a apreensão das drogas no local onde o réu WILIAN as dispensou, as quais ambos os acusados traziam consigo; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 75/77), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Havia aderência mútua de condutas, pois os acusados estavam juntos e ambos apresentaram conduta suspeita ao notar a presença dos Guardas Civis Municipais. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas porções, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo"; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; e 4) a apreensão de instrumentos destinados ao acondicionamento da droga (fls. 09/10). Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de

Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 75/77) e demonstrado que os réus incorreram em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis aos acusados, motivo pelo qual fixo a pena-base deles no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão ao réu Willian, nos termos da Sumula 231 do STJ, eis que pena se encontra no mínimo legal. Em relação ao corréu Jorge, não há agravantes ou atenuantes a incidir, de modo que mantenho a pena dos acusados inalteradas nessa etapa. Convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que os acusados se valeram das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto

Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminoso, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, em se tratando de réus primários, de bons antecedentes, que não integram organização criminosa, tampouco se dedicam a atividades ilícitas, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Aplica-se, no entanto, o redutor em questão em seu patamar intermediário, 1/2, devido a quantidade e a variedade de drogas. Nessa esteira, produz-se a reprimenda legal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva pela ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e a variedade de drogas. Consigno, por oportuno, que este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 - "Lei de Execução Penal" que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas"). Desde então, esse Juízo tem deixado de fixar, em tais casos, o regime mais severo para o início do cumprimento da pena, passando a estabelecer o regime inicial intermediário, conforme in casu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: 1) condenar os réus JORGE LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO e WILIAN DO NASCIMENTO FARIAS, devidamente qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver os acusados da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o Apelo em Liberdade, na medida em que os acusados responderam ao feito em liberdade, pelas razões mencionadas a fls. 41/42, e não sobrevieram motivos que exigissem a segregação cautelar deles. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 65) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 130,00 em dinheiro - fls. 09) em favor da União, apropriados os bens



ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelas Defensoras dos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "RECEBO os recursos interpostos pelas Defesas, saindo as Defensoras, desde já, intimadas a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novos Defensores. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competentes Certidões de Honorários. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o Trânsito em Julgado da condenação criminal, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Alisson Eduardo de Oliveira, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA